AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000953-87.2015.404.0000/RS

RELATOR	:	**Des. Federal ROGERIO FAVRETO**
AGRAVANTE	:	**CARLOS ANDRIEI SANTOS DE SOUZA**
ADVOGADO	:	**Mauro Antonio Volkmer e outro**
AGRAVADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	:	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

D.E.

Publicado em 29/05/2015

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. **BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL**. **INCAPACIDADE TEMPORÁRIA**. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. VEROSSIMILHANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO.

Para fins de concessão do **benefício assistencial**, não há exigência legal de que a incapacidade laboral seja definitiva, bastando que se trate de impedimento de longo prazo (no mínimo por dois anos), que obstrua a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade.

Demonstrada a verossimilhança quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do **benefício assistencial**, especialmente quanto à incapacidade laboral, é de ser provido o agravo de instrumento para se conceder a antecipação de tutela.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 5a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **dar provimento ao agravo de instrumento**, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de maio de 2015.

Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7407887v8** e, se solicitado, do código CRC **855EB09A**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Rogerio Favreto

Data e Hora: 20/05/2015 19:09

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000953-87.2015.404.0000/RS

RELATOR	**:**	**Des. Federal ROGERIO FAVRETO**
AGRAVANTE	**:**	**CARLOS ANDRIEI SANTOS DE SOUZA**
ADVOGADO	**:**	**Mauro Antonio Volkmer e outro**
AGRAVADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
ADVOGADO	**:**	**Procuradoria Regional da PFE-INSS**

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Luiz Gonzaga - RS que, **em ação objetivando a concessão de benefício de amparo social a criança portadora de deficiência, indeferiu o pedido de antecipação de tutela** nos seguintes termos:

> *"Vistos.*
>
> *Carlos Andriei Santos de Souza ajuizou a presente ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Narrou que encaminhou pedido de **benefício assistencial** ao INSS, mas seu pleito foi negado com a justificativa de não preenchimento dos pressupostos previstos na LOAS (Lei nº. 8.742/93) - requisito de impedimentos de longo prazo. Requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do benefício em comento. Pugnou pela procedência da ação com o pagamento do **benefício assistencial** de forma retroativa a data do agendamento do pedido em sede administrativa.*
>
> *É o breve relatório.*
> *Decido.*
>
> *A antecipação dos efeitos da tutela deve submeter-se à disciplina genérica do tema, prevista no artigo 273, do CPC, somente sendo possível sua concessão nos casos em que presentes, concomitante, os requisitos de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação.*
>
> *Impende destacar, que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os recursos extraordinários nº 567.985 e 580.963, submetidos à repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, assim como do artigo 34 do Estatuto do Idoso, circunstância que outorga ao julgador, na análise do caso concreto, verificar o estado de miserabilidade da parte autora e de sua família, a justificar a concessão do **benefício assistencial**. Contudo, no caso telado, a autarquia ré indeferiu o pedido da demandante em razão do não cumprimento de exigências, conforme demonstra o documento da fls. 97/99, porém, não tendo a parte autora juntado aos autos elementos de prova necessários a um juízo de cognição sumária, entendo que não há, neste momento, como reconhecer o direito ao benefício.*
>
> *Dessa forma, embora se possa falar em receio de dano, não há elementos suficientes à formação de juízo de verossimilhança do que sustenta a parte demandante.*
>
> *Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.*
> *DEFIRO a AJG.*
> *Intimem-se.*

Cite-se a autarquia requerida.
Com a contestação, dê-se vista à parte autora, para réplica.
Dil. Legais.

Em 12/02/2015

Roberta Penz de Oliveira,
Juíza de Direito." (fl. 116)

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, padecer de quadro depressivo com sintomas psicóticos e de epilepsia, necessitando de ajuda permanente de terceiros. Defende que a doença é congênita, não sendo, portanto, temporária. Sustenta viver em situação de extrema vulnerabilidade social. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento definitivo do agravo.

O agravo foi recebido e deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

VOTO

Por ocasião da decisão inicial assim me manifestei:

"(...)
É o breve relatório. Decido.

Os requisitos necessários à antecipação de tutela são expressos em lei, quais sejam: existência de prova inequívoca, hábil a produzir um juízo de ***verossimilhança*** *das alegações, e fundado receio de* ***dano irreparável ou de difícil reparação****.*

Para efeito de concessão do ***benefício assistencial****, a pessoa com deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, ou seja, aquela portadora de incapacidade que impede o exercício de atividade remunerada, o que deve ser analisado à luz do caso concreto.*

Em relação à criança com deficiência, deve ser analisado o impacto da incapacidade na limitação do desempenho de atividades e na restrição da participação social, compatível com a sua idade.

Trata-se de autor nascido em 04/03/2004. Dos documentos que instruem os autos (fls. 51/84), verifica-se a existência de vários receituários de medicação controlada assinados por neurologistas; fichas de atendimento médico-hospitalar, com referências a duas internações (em 10/2013 e 03/2014); exames médicos, como eletroencefalograma; e, inclusive, atestados médicos que remontam a dezembro de 2012 retratando o quadro de epilepsia, convulsões e tratamento psiquiátrico ao qual desde então esteve sujeito o autor.

Quando do requerimento administrativo - feito em setembro de 2014 e indeferido ao fundamento de que "os impedimentos constatados não produzem efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos" (fl. 113) - o art. 20 da Lei n.º 8.742/93 já vigorava com a redação atual, dispondo o seguinte:

"Art. 20 O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal

à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
(...)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, ***considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial****, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.*
(...)
§ 10. ***Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos****."*

Verifica-se, portanto, que não há exigência legal de que a incapacidade seja definitiva, mas, sim, de longo prazo. Nesse sentido decidiu a Turma Regional de Uniformização deste Tribunal no Incidente de Uniformização JEF nº 0001444-53.2007.404.7056/PR (Relatora Juíza Federal Susana Sbrogio Gália, D.E. 09/03/2011):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE JURISPRUDÊNCIA. ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****.* ***INCAPACIDADE TEMPORÁRIA****. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO QUADRO INCAPACITANTE. DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.*
1. Conforme precedentes desta Turma Regional e da Turma Nacional de Uniformização, "A transitoriedade da incapacidade não é óbice à concessão do ***benefício assistencial****, visto que o critério de definitividade da incapacidade não está previsto no aludido diploma legal. Ao revés, o artigo 21 da referida lei corrobora o caráter temporário do benefício em questão, ao estatuir que o benefício 'deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.'"(TNU, proc. 2007.70.50.01.0865-9, Relator Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, julgado na sessão de 16.11.2009)*
2. Em se encontrando o requerente incapacitado para atividades que garantam a sua subsistência, tem direito à concessão do ***benefício assistencial****.*
3. Incidente de uniformização conhecido e não provido.

Não é outra a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte a exemplo do recente precedente da Terceira Seção (à unanimidade) transcrito abaixo:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. ***BENEFÍCIO ASSISTENCIAL****. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ART. 20, §2º, DA LEI 8.742/93.* ***INCAPACIDADE TEMPORÁRIA****. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO. 1. O direito ao* ***benefício assistencial*** *previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei 8.742/93 (LOAS) pressupõe o preenchimento de dois requisitos: a) condição de pessoa com deficiência ou idosa e b) condição socioeconômica que indique miserabilidade; ou seja, a falta de meios para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. 2. Encontrando-se a parte autora incapacitada para o exercício de atividades que lhe garantam a subsistência, enquadra-se na acepção de pessoa com deficiência, prevista no § 2º, do art. 20 da Lei 8.742/93, com a redação atual, pois enfrenta impedimentos de longo prazo, de natureza física que, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3. Embora temporária a incapacidade, a parte autora faz jus ao* ***benefício assistencial*** *enquanto não recuperar a capacidade laborativa de forma a possibilitar sua inserção no mercado de trabalho. 4. Demonstrado pela análise do contexto fático probatório estar a parte autora em clara situação de risco social, necessitando do* ***benefício assistencial*** *para garantir uma sobrevivência digna, é de ser concedido o* ***benefício assistencial****. (TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0008200-03.2012.404.9999, 3ª SEÇÃO, Juiz Federal JOSÉ ANTONIO SAVARIS, POR*

UNANIMIDADE, D.E. 01/08/2014, PUBLICAÇÃO EM 04/08/2014)

Ainda no mesmo sentido, a Súmula n.º 48, da Turma Nacional de Uniformização:

> *"A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do* ***benefício assistencial*** *de prestação continuada." (DOU 18/04/2012)*

O conjunto probatório existente nos autos (mais especificamente os parecer médicos de fls. 60 e 64) confirma que a incapacidade do autor remonta, pelo menos, ao mês de dezembro de 2012. Ou seja, já se encontra neste estado por mais de 02 anos, o que é bastante para caracterizar impedimento de longo prazo.

Quanto ao requisito socioeconômico, as informações que se têm por ora são as de que se trata de família composta pelo autor, mais três irmãos menores e os pais. De consulta ao CNIS comprova-se que a mãe do autor não apresenta registro de qualquer vínculo laboral. O pai, desde julho de 2013, teve somente o registro de um vínculo de emprego em janeiro de 2015 com remuneração de R$ 212,08.

Diante destas circunstâncias, reputo demonstrada a verossimilhança bem como a urgência necessária a justificar a antecipação de tutela, sem prejuízo de eventual reconsideração após a complementação da instrução probatória cuja ***perícia médica e estudo socioeconômico (indispensáveis à elucidação da controvérsia) devem ser agilizados pelo Juízo de origem com a maior brevidade possível.***

Ante o exposto, ***defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao INSS a implementação do benefício assistencial em favor do Agravante no prazo de até 15 (quinze) dias.***

Vista ao Agravado para responder.

Intimem-se.

Porto Alegre, 10 de março de 2015"

Ante o exposto, voto por **dar provimento ao agravo de instrumento**.

Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7407885v6** e, se solicitado, do código CRC **779B04E2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Rogerio Favreto
Data e Hora:	20/05/2015 19:09

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 19/05/2015

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000953-87.2015.404.0000/RS
ORIGEM: RS 00013365320158210034

RELATOR	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
PRESIDENTE	:	Rogerio Favreto
PROCURADOR	:	Dr. Domingos Sávio Dresch da Silveira
AGRAVANTE	:	CARLOS ANDRIEI SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO	:	Mauro Antonio Volkmer e outro
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO	:	Procuradoria Regional da PFE-INSS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 19/05/2015, na seqüência 29, disponibilizada no DE de 27/04/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 5ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
VOTANTE(S)	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
	:	Des. Federal LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON
	:	Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA

Lídice Peña Thomaz
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por **Lídice Peña Thomaz, Diretora de Secretaria**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7563501v1** e, se solicitado, do código CRC **FB1AAECF**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lídice Peña Thomaz
Data e Hora:	20/05/2015 19:15